

1500261-71.2020.8.26.0071

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2023567/2020 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 6071812 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 18151/19/404 -

CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2023567 - CENTRAL ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500261-71.2020.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500261-71.2020.8.26.0071

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2023567/2020 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 6071812 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 18151/19/404 -

CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2023567 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 18151/19/404

- CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2023567 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU,

18151/19/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WASHINGTON LUIS PASCOALINO RAMOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

O acusado Washington Luis Pascoalino dos Santos, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33 c.c. artigo 40, III, ambos da lei nº 11.343/2006.

Segundo a denúncia, o acusado, no dia 08 de agosto de 2019, às 11h30min, no CPP Bauru, na Rodovia SP 300, km 353, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, foi surpreendido com 44 porções ou 42,33 gramas de cocaína, para fins de tráfico, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Boletim de ocorrência (fls. 07/08), auto de exibição/apreensão (fls. 09), laudo

definitivo (fls. 10/14).

Pela decisão de fls. 64/66, foi recebida a denúncia e determinada a citação do acusado.

O réu foi formalmente citado (fls. 85), tendo ofertado resposta à acusação (fls. 95/96).

Na decisão de fls. 103/105, houve a manutenção do recebimento da denúncia.

Às fls. 172, foi recebido o aditamento à denúncia, para constar o nome correto do acusado, qual seja, Washington Luis Pascoalino dos Santos.

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 181/183 foram ouvidas as testemunhas de acusação/defesa e interrogado o réu.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 193/197 pugnando, em suma, pela procedência da pretensão punitiva, nos termos da exordial, com a valoração do art. 42 da Lei nº 11.343/06, e dos antecedentes, a constatação da reincidência e da agravante do "estado pandêmico", afastando o "tráfico-privilegiado", com o emprego da causa de aumento descrita no art. 40, III da Lei Antidrogas, fixando-se o regime inicial fechado.

Já a Defensoria, às fls. 200/209, pleiteou, em síntese, pela absolvição por ausência de provas, ou o lançamento da pena no mínimo legal, fixando-se o regime inicial mais brando.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito de tráfico está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 07/08), auto de exibição/apreensão (fls. 09), laudo definitivo (fls. 10/14).

A autoria, de outra banda, induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

Os agentes penitenciários Rodrigo da Costa, João Elso Rosa e Reginaldo Farias, na fase judicial (mídia SAJ) em suma, reproduziram o que dito durante o procedimento administrativo disciplinar. Disseram que fizeram uma revista de rotina na cela do acusado. Afirmaram que, antes de encontrar a droga, foi perguntado a cada detento de quem era cada roupa existente na cela. Informaram que acharam porções de cocaína na bermuda do réu que estava em meio aos pertences dele. Esclareceram que havia entre quatro e cinco detentos naquela cela, sendo que o acusado assumiu a propriedade do entorpecente.

Aqui, uma ressalva.

Os depoimentos prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP.

Por isso, os relatos são chancelados pela jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE

PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE

NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO DE

DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.

RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO.

INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE

PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO.

DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos

policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

O acusado Washington Luis Pascoalino dos Santos, nome social Luara, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ) disse houve uma 'blitz' naquele dia. Afirmou que eles perguntaram se alguns pertences lhe pertenciam, tendo confirmado. Informou que os agentes encontraram drogas em suas vestes. Esclareceu que como havia vários integrantes de 'facção criminosa PCC' por perto, assumiu a propriedade da droga. Mencionou que eram cinco pessoas na cela, e, por ser homossexual, havia uma opressão por parte dos integrantes da 'facção criminosa PCC'.

Pela prova colhida, é de rigor a condenação pelo delito de tráfico de drogas.

O acusado, na fase judicial, alegou que sofria ameaças, sem detalhamento ou apontar os supostos autores de tais ameaças.

Entretanto, durante a fase administrativa (fls. 29/30), disse que guardava o entorpecente há 3 ou 4 dias, em razão de dívidas por ser usuária.

Ou seja, a versão é contraditória, até porque, as ameaças jamais foram delineadas.

Depois, estranhamente, a acusada jamais pleiteou pelo isolamento celular, nos moldes do art. 50 do Regimento Interno da SAP: Artigo 50 - Deve ser aplicada a medida preventiva de segurança pessoal, quando, provocada pelo próprio interessado ou quando pesem informações, devidamente fundamentadas, de que estaria ameaçada sua integridade física, observando-se, nesse caso, as normas específicas da Secretaria da Administração Penitenciária, das coordenadorias regionais e das unidades prisionais, quanto aos procedimentos a serem adotados e seus respectivos prazos.

§1º - Nos casos em que a medida preventiva de segurança pessoal for solicitada pelo próprio interessado, deve, o pedido, ser feito por escrito ou colhida sua declaração, devendo em ambos, constar as razões que levaram à solicitação. §2º -

Nos casos de adoção da medida preventiva de segurança pessoal, sem prejuízo dos prazos estipulados, deve o preso, manifestar-se, por escrito, pela continuidade ou não, a cada 30 (trinta) dias. §3º - As celas destinadas à medida preventiva de

segurança pessoal devem ser totalmente separadas das alas destinadas ao restante da população prisional, não sendo admitido agrupar os presos vulneráveis em alas ou celas de destinação diversa desse fim.

Portanto, a ameaça, por não comprovada, faz com que a menção reste isolada no feito, em detrimento aos depoimentos dos agentes.

Neste contexto, impõe-se o decreto condenatório pelo delito previsto no art. 33 "caput" da Lei nº 11.343/06.

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

A ré não possui antecedentes criminais (fls. 187/189).

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Contudo, a natureza (cocaína), denota que a pena deve ser exasperada em 1/5, perfazendo 6 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa.

Isto por que, o art. 42 da Lei nº 11.343/06 preconiza que a natureza, bem como a quantidade de drogas, são circunstâncias preponderantes.

Tal conclusão é amparada pela jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA REDUÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.

FUNDAMENTO IDÔNEO. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA

NA PRIMEIRA OU NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL. DESPROVIDO.

I - Conforme orientação do col. STF, a circunstância desfavorável da natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos pode ser considerada ora na primeira fase, para exasperar a pena-base, ora na terceira fase da dosimetria, impedindo a aplicação ou modulando a fração de redução da minorante contida no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

II - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

III - No presente caso, afastou-se o privilégio descrito no parágrafo 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ao fundamento de que o agravante se dedicava às atividades criminosas, lastreando-se na natureza e quantidade de droga apreendida, qual seja, 348 (trezentos e quarenta e oito) pedras de crack, 2 (dois) cigarros de maconha, 18 (dezoito) pinos de cocaína e 2 (duas) porções de maconha, além da apreensão de 1 (uma) arma de fogo, calibre 380 e 35 (trinta e cinco) munições do mesmo calibre. Assim, a fundamentação exarada é adequada ao caso concreto e justifica o afastamento da figura do tráfico privilegiado.

IV - "[...] A questão discutida neste recurso especial não demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento que é obstado pela Súmula n. 7 deste Superior Tribunal, tal como ocorre, por exemplo, com a valoração das circunstâncias judiciais (uma a uma). O caso, diversamente, demanda apenas o reexame da aplicação da pena, providência admitida em caráter excepcional, nas hipóteses de manifesta violação aos critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal e do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, sob o aspecto da legalidade, nas hipóteses de falta ou de equívoco evidente de fundamentação das circunstâncias judiciais (como no caso) ou, ainda, de erro de técnica no critério trifásico de aplicação da pena" (AgRg no REsp n. 1.475.447/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2015).

Agravo regimental desprovido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp 1753254 / MG, relator ministro Felix Fischer, julgado em 09/10/2018)

Na segunda fase, a acusada é multireincidente (dois delitos de furto, e outro, específico, por tráfico).

São eles, respectivamente, processos nº 8009-91.2016, 4397-14.2017 e 6784-41.2013. Assim, a pena deve ser agravada em 1/3, atingindo 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentas) diárias.

Ainda na fase intermediária, quanto à agravante do "estado pandêmico" deve ser revisto posicionamento anterior, eis que, atualmente, salvo melhor juízo, a jurisprudência majoritária a tem afastado, dentre outras, no que toca à fundamentação no sentido de que 'não há informações de que o cometimento da infração tenha sido facilitada pela Covid-19'.

É o entendimento da Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas - Autoria e materialidade demonstradas - Prova suficiente à condenação - Tipicidade formal e material da conduta presentes - Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública - Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer o delito - Não reconhecimento da participação de menor importância - Causa de aumento previstas no inciso VI, do artigo 40, mantida, eis que o delito praticado envolveu menor - Concessão de regime inicial aberto - Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito - Recurso parcialmente provido.

(TJSP, 12ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 1504300-

91.2021.8.26.0228, relator Des. Amabale Lopez Soto, julgado em 29/10/2021)

Na derradeira, inaplicável o redutor previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06. Com efeito, a acusada é multireincidente específico.

Nem se fale que haveria bis in idem na utilização da reincidência na segunda fase e na derradeira, porque o instituto é utilizado de maneira diversa.

Na intermediária, a reincidência é fator para agravar a pena, já que sempre deve

agravar a reprimenda, nos estritos termos do art. 61 "caput" do Código Penal, e, ressalvadas as hipóteses legais.

Já na última fase é pressuposto para negar o redutor previsto no art. 33, §4º da lei 11343/06, salientando-se que os requisitos lá plasmados são cumulativos.

A variação da diminuição na minorante é cotejada com fatores diversos, tais como quantidade e natureza da droga (quando não utilizados na primeira fase), as circunstâncias da ocorrência, a personalidade da acusada, ou seja, de modo geral, o próprio art. 42 da lei 11343/06.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Corte estadual, na terceira fase da dosimetria, sopesou não apenas a natureza e a quantidade de entorpecentes apreendidos, mas também as demais circunstâncias em que perpetrado o delito para concluir que os acusados se dedicariam a atividades delituosas, especialmente ao narcotráfico, motivo pelo qual não há falar em bis in idem.

2. A simples reincidência dos réus já é elemento suficiente para, por si só, impedir a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, haja vista a vedação legal expressa da concessão desse benefício aos acusados reincidentes.

3. Se ainda não houver decorrido o prazo de 5 anos entre a data do cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior, a condenação anterior é geradora de reincidência, independentemente de ela ser ou não pela prática do mesmo delito.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AREsp 1382648 / SP, por unanimidade, relator ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 18/06/2019)

Ainda na mesma fase, presente a majorante inculpada no art. 40, III da Lei Antidrogas, visto que a droga foi encontrada nos pertences da acusada, dentro de uma cela.

Assim, a reprimenda deve ser aumentada em 1/6, totalizando, em definitivo, 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa. O valor de cada dia-multa é de 1/30, face a ausência de informações necessárias no tocante à situação econômica dos acusados.

Fixo o regime inicial fechado.

A acusada é multireincidente, em parte, específica.

Além disso, o art. 42 da Lei nº 11.343/06 (nos termos do art. 33, §3º do Código Penal) não foi considerado inteiramente favorável.

Depois, é responsabilizada por outro feito em curso nesta unidade carcerária, pela mesma prática delituosa, cometido em 21/01/2020 (autos nº 1500180-25.2020).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE REINCIDENTE. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA ACIMA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO E REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao pleito de aplicação do princípio da insignificância, prevalece neste Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida.

2. A pretensão de absolvição ou de desclassificação do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n.º 11.340/2006 para o art. 28 da referida norma não pode ser apreciada por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por

demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos.

3. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

4. Em relação à redutora do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, a sua aplicação demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar à atividades criminosas ou integrar organização criminosa. No caso dos autos, o paciente é reincidente, não fazendo jus a aplicação da redutora.

5. Quanto ao regime, tendo em vista que a pena é superior a 4 anos de reclusão e o paciente é reincidente, o regime inicial fechado é mais adequado ao caso, conforme dispõe o art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

6. Não há se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o quantum da pena supera o limite previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal.

7. Agravo regimental improvido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 695249 / SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 26/10/2021)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL, e, deste modo, CONDENO Washington Luis Pascoalino dos Santos, nome social Luara, qualificada nos autos, a cumprir a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, com diárias no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 33 "caput" c.c. 40, III ambos da Lei nº 11.343/06.

A acusada respondeu ao feito em liberdade, e nesta condição poderá recorrer, na ausência de provação do juízo e novos elementos a alterar o binômio liberdade versus prisão.

Quanto aos entorpecentes apreendidos, autorizo a destruição.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno a acusada a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

P.R.I.C.

Bauru, 28 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA